

1500154-58.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. "É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-

3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500154-58.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2027007/2021 - 02º D.P. PIRACICABA, 15950100 - 02º D.P. PIRACICABA, 2027007 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDGARD CLEMENTE JÚNIOR

Vítima:

JOSE MARIA RIBEIRO

Artigo da Denúncia:

*

Aos 23 dias do mês de junho de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) EDGARD CLEMENTE JÚNIOR e a testemunha arrolada pela defesa Erick Adriano Tertuliano Augusto. Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. Pela defensora, após conversa em apartado com o réu, foi informado que a mãe do réu, sra. Lucilene reside no mesmo local. Pelo réu foi informado o telefone da genitora, tendo sido enviado link da

audiência via whats app. Porém, após inúmeras tentativas frustradas de ingresso da referida testemunha em audiência, pela defensora foi dito que desistia de sua oitiva.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) da defesa (Erick) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s).

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, EDGARD CLEMENTE JÚNIOR está sendo processado como incursos no artigo 180, caput, do Código Penal.

Feito regularmente processado.

Procede a ação penal.

DOS FATOS

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre os dias 21 e 29 de janeiro de 2021, nesta cidade e comarca, EDGARD CLEMENTE JÚNIOR, qualificado e indiciado a fls. 05, recebeu e conduziu, em proveito próprio ou alheio, o veículo Honda/Twister, placa ECJ-9649, cor amarela, pertencente a José Maria Ribeiro, coisa que sabiam ser produto de crime. Segundo foi apurado, o veículo acima descrito foi subtraído no dia 21 de janeiro 2021, por pessoas desconhecidas, neste município de Piracicaba/SP (RDO 163/21 do 1º D.P, e declarações de fls. 04). Posteriormente, em circunstâncias não esclarecidas, o denunciado recebeu o automotor e passou a conduzi-lo pelas vias deste município, até que, no dia 29 de janeiro de 2021, foi abordado e detido por guardas municipais. A motocicleta ostentava a “placa artesanal” RFF-9030, que, em consulta, constatou-se pertencer a um veículo Ford/Ka de Belo Horizonte/MG. E em pesquisas pelo número do chassi, verificou-se que a placa original era ECJ-9649 (com registro de furto - RD0163/21, 1º D.P). Por fim, os guardas constataram que a cor original (amarela) tinha sido grosseiramente alterada para o vermelho.

O denunciado ficou em silêncio na Delegacia de Polícia (fls. 05), mas, diante das circunstâncias acima descritas, é certo que ele tinha ciência de que a motocicleta era produto de origem ilícita. Auto de exibição e apreensão de fls. 10.

DA PROVA JUDICIAL

José Maria Ribeiro – vítima – declarou que sua motocicleta foi furtada, fez boletim de ocorrência e depois ela foi localizada. Foi avisado e chamado até a Delegacia de Polícia. Reconheceu a moto como sendo de sua propriedade, embora o documento estivesse em nome de outra pessoa. Sua moto era amarela, mas foi encontrada pintada na cor vermelha.

Francisco Dermival, GCM, narrou que foi avisado que uma pessoa de nome Eric estava fazendo manobras perigosas com uma motocicleta vermelha. Solicitou auxílio de motociclistas porque as vielas da comunidade portelinha são estreitas. Parte dos agentes desembarcaram e entraram a pé. Logo que entraram viram o réu na motocicleta tentando faze-la funcionar. Ele viu os guardas, abandonou a motocicleta e tentou fugir. Foi detido. Ele disse que se chamava Gabriel, mas o depoente o reconheceu porque já o prendera enquanto adolescente na receptação de um veículo juntamente com seu irmão. Sabia que ele era o EDGARD. A placa da motocicleta, em pesquisa, era de um veículo Ford Ka. Pelo chassi e motor, viu que era moto produto de furto. Que a cor original era amarela, mas ela ostentava uma cor vermelha, de uma pintura bem grotesca. Na Delegacia, ele disse que a moto era do irmão dele, de nome Eric. Ele não disse a moto chegou em sua posse. A placa era visivelmente artesanal.

No mesmo sentido, o GCM Felipe V. Alves.

A testemunha de defesa Erick Adriano Tertuliano Augusto, irmão do réu e preso por outro crime, disse que a moto era sua. Assumiu a responsabilidade pelo veículo e disse que seu irmão não tem nada a ver. Que ele estava cortando o cabelo. Estava na casa de seu pai e não viu seu irmão ser abordado, só depois que levaram ele para a Delegacia. Seu irmão não usava a motocicleta. Que era o declarante quem estava empinando a moto momentos antes.

Versão incrível. Preso, o irmão do réu tenta desesperadamente livrar a responsabilidade do réu. Mas não há como se olvidar que foi o réu a pessoa presa em poder da motocicleta. Logo que entraram, viram o réu na motocicleta tentando fazê-la funcionar. Ele viu os guardas, abandonou a motocicleta e tentou fugir. Foi detido. É certo que estava na posse do objeto ilícito e que, portanto, o recebera em circunstâncias que tornam certo que sabia da origem espúria do veículo. Interrogado, o réu EDGARD disse que não possuía a moto, não andou na moto, não sabia que era de origem ilícita. Que estava cortando o cabelo com o Elias e viu os policiais passarem na frente. Uma hora, foi chamado com mais três pessoas. Foi abordado e reconhecido pelos guardas. A moto estava três ou quatro casas para baixo.

Outra versão impossível de crédito. O réu disse que cortava o cabelo com outras três pessoas, mas não trouxe nenhuma delas, nem o cabelereiro Elias, para depor a seu favor, para confirmar a sua - inacreditável - versão.

TAMBÉM É CERTO QUE O RÉU TINHA CIÊNCIA DA ORIGEM ESPÚRIA DA MOTOCICLETA: como dito, a motocicleta ostentava a "placa artesanal" RFF-9030, que, em consulta, constatou-se pertencer a um veículo Ford/Ka de Belo Horizonte/MG. E em pesquisas pelo número do chassi, verificou-se que a placa original era ECJ-9649 (com registro de furto - RD0163/21, 1º D.P). Por fim, os guardas constataram que a cor original (amarela) tinha sido grosseiramente alterada para o vermelho.

E o réu tentou fugir ao ver a viatura.

E o réu forneceu inicialmente nome falso aos agentes policiais.

Tudo a demonstrar com certeza que o réu sabia da origem ilícita da moto.

E mais, ainda que a motocicleta fosse de "propriedade" de seu irmão, ainda que este fosse o receptor original do veículo, em algum momento, o réu, mesmo sabendo da origem ilícita, o recebeu.

TACRSP: "Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento 'ab externo, do modus operandi' do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva" (RJDTACRIM 35/285-6).

DA PENA:

Folha de antecedentes e certidões nos autos: reincidência (0001590-68.2017.8.26.0599 e 1500078-39.2018.8.26.0599 (fls. 33/45).

Pena acima do mínimo legal.

Regime fechado.

DO PEDIDO FINAL

Pela procedência da ação nos termos da inicial.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, Edgard Clemente Júnior foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls. 60-61), entre os dias 21 e 29 de janeiro de 2021, nesta cidade e comarca, Edgard teria recebido e conduzido, em proveito próprio ou alheio, o veículo Honda/Twister, placa ECJ-9649, cor amarela, pertencente a José Maria Ribeiro, coisa que sabiam ser produto de crime.

Ainda de acordo com a inicial, o veículo acima descrito foi subtraído no dia 21 de janeiro 2021, por pessoas desconhecidas, neste município de Piracicaba/SP (RDO 163/21 do 1º D.P, e declarações de fls. 04). Posteriormente, em circunstâncias não esclarecidas, o réu recebeu o automotor e passou a conduzi-lo pelas vias deste município, até que, no dia 29 de janeiro de 2021, foi abordado e detido por guardas municipais. A motocicleta ostentava a "placa artesanal" RFF-9030, que, em consulta, constatou-se pertencer a um veículo Ford/Ka de Belo Horizonte/MG. E em pesquisas pelo número do chassi, verificou-se que a placa original era ECJ-9649 (com registro de furto - RD0163/21, 1º D.P). Por fim, os guardas constataram que a cor original (amarela) tinha sido grosseiramente alterada para o vermelho.

Interrogado em solo policial, o réu exerceu o seu direito constitucional ao silêncio

José Maria Ribeiro, vítima, contou que: “comprou a motocicleta Honda/Twister, de placa ECJ-9649 de cor amarela, há aproximadamente cinco anos da pessoa de Tatiana Santos de Oliveira, porém o nome que consta na transferência é o de sua amiga Estér, e que por motivos financeiros não transferiu a mesma para seu nome. Na data de vinte e um de janeiro do presente ano, estava em um bar e quando saiu por volta de uma hora da manhã, não encontrou mais sua motocicleta que estava parada em frente ao bar. Na data de hoje recebeu um telefonema desta Delegacia o informando de que sua motocicleta havia sido encontrada. Visualizou a motocicleta apreendida e que constatou diversos danos, bem como percebeu que ela já não ostentava a cor amarela e sim vermelha. O valor atual da motocicleta em questão é de cinco mil e quinhentos reais” (fls. 4).

Francisco Dernival Miranda Junior, guarda municipal, narrou em solo policial que: “na data de hoje, estavam em patrulhamento na companhia GCM Vieira a bordo da viatura 92 nas redondezas do bairro Jd. São Paulo nesta cidade, quando foram solicitados por um transeunte dizendo que dentro da comunidade Portelinha teria um indivíduo de prenome Erick, cujo o pai se chamava Adilson, e que este estaria com uma motocicleta vermelha realizando manobras perigosas quase atropelando pedestres. O transeunte ainda disse ter ouvido na comunidade que a motocicleta era produto de roubo. Solicitaram apoio e uma equipe de motocicletas da Guarda Municipal cercou a saída da comunidade sendo que ao adentrarem na Viela visualizaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta vermelha, este ao visualizar a equipe do depoente jogou a motocicleta no chão e tentou se evadir, porém foi abordado logo em seguida. Realizaram busca pessoal, porém nada de ilícito encontraram, questionaram seu nome e inicialmente este forneceu nomes falsos, mas acabou por informar seu verdadeiro nome, sendo identificado como Edgard Clemente Junior. Perceberam que a motocicleta ostentava uma placa artesanal RFF-9030, a qual após consulta verificou-se estar relacionada a um veículo Ford/Ka de Belo Horizonte, então verificaram a numeração do chassi sendo esta 9C2MC35008R129700 e do motor, sendo que coincidiam com a numeração de uma motocicleta Honda/Twister de placa ECJ-9649 com queixa de furto conforme RD0163/21 do 1º D.P. Piracicaba. O registro da motocicleta Honda /Twister indicava que a mesma era de cor amarela, salientando que a pintura vermelha era visivelmente pintada a mão. Diante dos fatos, deram voz de prisão a Edgard tendo sido necessário o uso de algemas devido a fundado receio de fuga e o conduziram até esta Delegacia para as devidas providências. Nesta Delegacia, Edgard disse que a motocicleta em questão era de seu irmão Erick, que morava na mesma comunidade, mas não sabia informar a casa” (fls. 2).

No mesmo sentido a versão apresentada por Felipe Vieira Alves, também guarda municipal (fls. 3).

Boletins de ocorrência juntados às fls. 7-9 e 63-64; auto de exibição e apreensão, às fls. 10.

Às fls. 35-45, juntadas certidões de objeto e folha de antecedentes que indicam a reincidência do requerido (autos n.º 0001590-68.2017.8.26.0599 – receptação – trânsito em julgado para a Defesa em 10/4/2019; autos n.º 1500078-39.2018.8.26.0599 – tráfico de drogas – trânsito em julgado para a Defesa em 27/2/2020).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

Em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Ouvido, inicialmente, José Maria Ribeiro. Relatou que a sua moto foi furtada. Fez boletim de ocorrência. Foi localizada posteriormente. Foi até a delegacia e a moto estava no pátio. Reconheceu a sua moto, mas o documento estava em nome de outra pessoa. A moto estava intacta. A sua moto era amarela, mas quando foi devolvida estava pintada de vermelho. Sabe que pessoas foram presas por conta do furto da moto, mas não chegou a vê-las.

b) Na sequência, foi ouvido Francisco Dernival Miranda Junior, guarda municipal. No dia dos fatos, patrulhavam e foram solicitados por um senhor dizendo que dentro da comunidade Portelinha um indivíduo conduzia uma moto fazendo manobras. O nome do indivíduo era Erick, o pai se chamava Adilson. Solicitaram auxílio da equipe de motocicletas da guarda. Andando na comunidade, viram o réu na motocicleta vermelha, tentando fazê-la funcionar. Ele se evadiu, mas conseguiram detê-lo. Inicialmente, o réu disse que se chamava Gabriel. Mas o reconheceu porque, quando adolescente, já o

tinha apreendido. Lembrou-se que o seu nome era Edgard. Ele então forneceu os dados pessoais e permaneceu calado sobre a motocicleta. Consultaram a placa e viram que se tratava da placa de um Ford Ka. Pesquisaram chassi e motor e apuraram que a motocicleta era fruto de furto e sua cor original era amarela. Somente na delegacia o réu afirmou que a motocicleta pertencia ao irmão. A placa era visivelmente artesanal.

c) Depois, foi ouvido Felipe Vieira Alves, guarda municipal. Trouxe aos autos as mesmas informações do seu companheiro de farda.

d) Ouvida a testemunha Eric Adriano Tertuliano Augusto. É irmão do réu. A moto estava com ele, estava parada. Alguém deve ter falado para os policiais que a moto estava com ele. Os policiais foram e pegaram o seu irmão, que não tem nada a ver com o ocorrido e estava cortando cabelo. No momento da prisão, estava na casa do seu pai. Não viu o irmão ser abordado, somente quando o levaram para a delegacia. O irmão não estava com a moto. Foi ele quem adquiriu a moto e estava andando na moto pelo bairro no dia dos fatos. Deparou-se com uma viatura e a estacionou, deixou-a parada e foi para a casa do pai.

e) Por fim, interrogado, o réu Edgard Clemente Júnior. Relatou que a moto era do seu irmão Eric. Estava no cabeleireiro quando foi preso e acusado pelos guardas. Os “policiais” passaram na frente do salão de cabeleireiro diversas vezes, ele viu. Até que mandaram sair do salão de cabeleireiro, mandaram ele e outras pessoas saírem. Um dos “policiais” lhe reconheceu, disse que ele era irmão do Eric, insistiu que ele dissesse onde estava o seu irmão. Ele disse que não sabia. Acabou sendo conduzido para a delegacia. Não andou na moto, nem sabia dessa moto. A moto estava há 3 ou 4 casas de onde ele estava. Na delegacia, disse que não era ele, falou tudo o que contou hoje. A mãe chegou, disse que não era esse o filho que estava com a moto. Não tem nada contra o dono da motocicleta ou contra os guardas.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Conforme as provas produzidas nos autos, não restou comprovada a autoria delitiva. Os guardas municipais receberam denúncia de que ERIC estava em posse da motocicleta, fazendo manobras nas ruas do bairro.

Ali chegando, acabaram por prender Edgard.

Não há nos autos e no depoimento dos guardas clareza quanto à localização do réu sobre a moto. O que disseram é que avistaram a pessoa na moto, ela se evadiu e, depois, conseguiram prender alguém. Eric contou, em seu depoimento, que a pessoa que viu a viatura e se evadiu era ele, e não o seu irmão Edgard. Sendo irmãos e de mesma compleição física e aparência próxima, não surpreende que os guardas possam ter se confundido.

Certo é que os guardas foram apurar denúncia contra ERIC e não há nos autos prova suficiente contra Edgard. Ao contrário, ERIC assumiu a autoria delitiva.

É o caso, portanto, de absolvição por insuficiência probatória.

- SUBSIDIARIAMENTE: DESCLASSIFICAÇÃO

No presente caso, tem-se que a conduta imputada ao réu é atípica porque não foi demonstrado, em juízo, que ele efetivamente sabia da origem ilícita do bem. É dizer: não foi demonstrado em juízo o tipo subjetivo da conduta tipificada pelo art. 180, caput, do Código Penal.

Com efeito, o tipo do art. 180, caput, do Código Penal apresenta a seguinte redação: “Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.

Conforme se percebe pela leitura da parte destacada acima, o tipo penal em questão somente pode ser cometido com dolo direto, eis que se exige que o agente saiba que o bem era produto de crime; a redação é, pois, incompatível com o dolo eventual. A título comparativo, basta analisar a redação do art. 180, § 1º, do Código Penal, dispositivo em que se evidencia a possibilidade de cometimento do delito com o dolo eventual.

É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao aduzir que:

Receptação/receptação qualificada (punibilidade menor/maior). Lei nº 9.426/96

(imperfeições). Norma/preceito secundário (desconsideração). [...] 2. Fruto da Lei nº 9.426/96, o § 1º do art. 180 do Cód. Penal “receptação qualificada” reveste-se

de imperfeições formal e material. É que não é lícita sanção jurídica maior (mais grave) contra quem atue com dolo eventual (§ 1º), enquanto menor (menos grave) a sanção jurídica destinada a quem atue com dolo direto (art. 180, caput). [...] (REsp 1094916/RS, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 13/10/2009, grifamos).

No mesmo sentido é a lição de Luiz Regis Prado: “Em face da expressão empregada pelo legislador, que sabe, o delito só pode ser praticado, no tocante caput, com dolo direto, não sendo possível a admissão do dolo eventual” (Comentários ao Código Penal. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 601).

Ora, os elementos de prova produzidos em juízo apenas permitem concluir que o acusado estava na posse do bem, mas não que, efetivamente, sabia de sua origem ilícita.

Assim, é o caso de desclassificação da conduta, amoldando-a ao disposto no art. 180, § 3º, do Código Penal, tendo em vista que não há nos autos prova de que o requerido sabia da origem ilícita do bem.

Nesse sentido:

O dolo do crime de receptação própria é a vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa, ou a de influir para o terceiro o faça. Exige-se, porém, que o agente saiba que se trata de coisa produto de crime. Não basta, pois, a dúvida quanto à origem da coisa, própria do dolo eventual, o que caracteriza, nos termos legais, a receptação culposa. (Código Penal Interpretado, Terceira Edição, Ed. Atlas, 2003, p. 1454).

Diante do exposto, requer-se a absolvição do assistido por ausência de dolo na prática do delito imputado na denúncia. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda que não seja possível a absolvição, requer-se a desclassificação do delito de receptação qualificada para receptação culposa, conforme previsão do art. 180, § 3º, do Código Penal.

- ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

Na remota hipótese de condenação, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior.

Na segunda fase dosimétrica, há a circunstância agravante da reincidência que permite o aumento da pena em 1/6.

Ausentes atenuantes, assim como causas de aumento ou diminuição.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, em atenção ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação de regime diverso do fechado.

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Por fim, considerando que o requerido respondeu ao presente processo em liberdade, não praticou crime com violência ou grave ameaça e não representa perigo à segurança da sociedade, requer-se que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

EDGARD CLEMENTE JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, porque entre os dias 21 e 29 de janeiro de 2021, nesta cidade e comarca, recebeu e conduziu, em proveito próprio ou alheio, o veículo Honda/Twister, placa ECJ-9649, cor amarela, pertencente a J.M.R., coisa que sabia ser produto de crime.

Segundo a denúncia, o veículo acima descrito foi subtraído no dia 21 de janeiro 2021, por pessoas desconhecidas, neste município de Piracicaba/SP (RDO 163/21 do 1º D.P, e declarações de fls. 04).

Posteriormente, em circunstâncias não esclarecidas, o réu recebeu o automotor e passou a conduzi-lo pelas vias deste município, até que, no dia 29 de janeiro de 2021, foi abordado e detido por guardas municipais.

A motocicleta ostentava a "placa artesanal" RFF-9030, que, em consulta, constatou-se pertencer a um veículo Ford/Ka de Belo Horizonte/MG. E em pesquisas pelo número do chassi, verificou-se que a placa original era ECJ-9649 (com registro de furto - RD0163/21, 1º D.P). Por fim, os guardas constataram que a cor original (amarela) tinha sido grosseiramente alterada para o vermelho.

O réu ficou em silêncio na Delegacia de Polícia (fls. 05), mas, diante das circunstâncias acima descritas, é certo que ele tinha ciência de que a motocicleta era produto de origem ilícita.

Auto de exibição e apreensão de fls. 10.

A denúncia foi recebida (fls. 65/66), o réu citado (fls.73), apresentando resposta escrita, na qual alegou que não há questões preliminares e o mérito será julgado posteriormente (fls. 77).

O recebimento da denúncia foi ratificado, designando-se audiência virtual (fls. 78/80).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima, 02 testemunhas comuns (fls. 99/101) e 01 testemunha de defesa, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

I - Da Preliminar

Pleiteia a Defesa, o reconhecimento da nulidade do processo, em razão da prisão realizada por guardas municipais. Argumenta que houve diligência típica de atividade policial, não permitida aos guardas municipais.

Não há, contudo, qualquer nulidade na prisão em flagrante do réu.

Não se verifica qualquer abuso ou ilegalidade na diligência efetuada pelos guardas municipais que apenas foram à comunidade e presenciaram o réu, ao perceber a aproximação policial, abandonado a motocicleta e tentando fuga, quando o abordaram. Por fim, a Lei nº 13.022/14 conferiu expressamente à Guarda Municipal a atribuição de polícia ostensiva, nos termos do artigo 3º da referida legislação, que assim dispõe: "Artigo 3º. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III - patrulhamento preventivo; IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e V - uso progressivo da força".

De qualquer modo, nada obstante o disposto no artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, é certo que, à luz do artigo 301 do Código de Processo Penal, não há uma proibição de que os guardas municipais prendam alguém em flagrante, haja vista que qualquer pessoa do povo também pode fazê-lo.

E, no caso concreto, o réu foi abordado na posse da motocicleta subtraída, logo após a denúncia, havendo flagrante, consoante prevê o artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal - CPP.[...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.º 603.686/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021) Ante o exposto, não conheço o presente habeas corpus. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator. (STJ - HC: 676532 SP 2021/0199414-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 29/06/2021).

"O recurso comporta parcial provimento. No caso, quanto à prisão em flagrante realizada por guardas municipais, inexistente ofensa aos alegados dispositivos de lei federal, pois o entendimento do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte consolidada no sentido de que, "apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão" (HC n. 286.546/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,

Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 15/10/2015). Nesse sentido, confira-se ainda: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. "É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal" (HC 471.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 1º/3/2019) 5. Habeas Corpus não conhecido. (HC 525.772/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019). Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para, na segunda fase da dosimetria, compensar integralmente a agravante de reincidência com a atenuante de confissão, fixando a pena definitiva do paciente em 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 11 dias-multa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator (STJ - Resp: 1940142 SP 2021/0159530-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 28/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO FLAGRANCIAL ILEGAL. GUARDA MUNICIPAL PODE PROMOVER PRISÃO EM FLAGRANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. 2. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 667413 SP 2021/0152075-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

Nesse sentido também o Tribunal de Justiça de São Paulo:

PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. FALTA DE COMPETÊNCIA PARA O ATO. INEXISTÊNCIA. O Estatuto das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/14), regulamentou o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, estabelecendo que compete à Guarda Civil Metropolitana, entre outras atribuições, prevenir, inibir e coibir infrações penais, bem como encaminhar indivíduos em flagrante delito à autoridade policial (art. 5º, II, III e IV da referida Lei). Ademais, como qualquer do povo, esses servidores podem efetuar a prisão em flagrante do agente cuja conduta se amolde às hipóteses taxativas do artigo 302 do Código de Processo Penal. Guardas civis municipais que foram alertados por transeunte sobre a conduta do réu, dirigiram-se ao local, observaram a prática de atos típicos de traficância e efetuaram sua prisão em flagrante delito. Ausência de ilicitude da busca pessoal que culminou na apreensão das drogas e dinheiro e o início da persecução penal. Preliminar rejeitada. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Guardas civis, após denúncia de traficância, avistaram o réu Yan em movimentação típica de tráfico com dois indivíduos e o surpreenderam na posse de duas porções de cocaína, vindo a localizar, no local de onde empreendera fuga, outras cinco porções da mesma droga, idênticas, e R\$ 20,00. Silente na fase extrajudicial, apelante negou em juízo o tráfico de drogas. Negativa e versão judiciais, além de fantasiosas e inverossímeis, sucumbiram à prova produzida pela Acusação. Condenação mantida. PENAS. Base fixada no mínimo legal. Pleito ministerial atendido para reconhecer-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, haja vista a prática do crime durante o estado de calamidade pública da pandemia de COVID-19, mormente no caso dos autos, em que se apura crime que visa a resguardar a saúde pública. Mantido o reconhecimento da reincidência. Negada a aplicação do redutor, por vedação legal expressa. Pena majorada. REGIME PRISIONAL. Regime

inicial fechado mantido, ante a quantidade de pena aplicada e a reincidência específica, além da gravidade concreta do delito praticado. Regime inicial fechado mantido. BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabíveis o sursis penal e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ante a quantidade de pena corporal (superior a quatro anos) e a reincidência específica do réu. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo defensivo desprovido, com provimento ao recurso ministerial para, reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, redimensionar suas penas para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa mínimos, com expedição de ofício de recomendação em seu desfavor. (TJ-SP - APR: 15015986320208260599 SP 1501598-63.2020.8.26.0599, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 29/06/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/06/2021 - grifei).

"Pondera-se, também, que em casos como o dos autos, por ser o tráfico de drogas um delito permanente, possível é a prisão flagrancial, a qualquer tempo e por qualquer um do povo, a teor do que dispõe o art. 301 do Código de Processo Penal. Destarte, não há impedimento legal para que membro da Guarda Civil Metropolitana efetue prisões em flagrante. Nesse sentido é a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE EFETUADO POR GUARDA MUNICIPAL. VALIDADE. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte Superior, é possível que, diante de notícia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, o agente municipal proceda à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estaria desautorizado a agir. 2. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. Precedentes. [...] 8. Ordem denegada. (HC 583.610/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020). PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. CONDUTA FLAGRADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. [...] III - O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). IV - Firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes." (HC 357.725/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 12/5/2017). [...] Habeas corpus não conhecido. (HC 480.676/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. 1. Não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante e, consequentemente, em prova ilícita, porque efetuada por guardas municipais, que estavam de ronda e foram informados da ocorrência da prática de tráfico de drogas na ocasião, se pode fazê-lo qualquer do povo (artigo 301 do Código de Processo Penal). 2. Recurso improvido. (RHC 20.714/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2007, DJe 04/08/2008). (TJ-SP - RVCr: 22502921020198260000 SP 2250292-10.2019.8.26.0000, Relator: João Morenghi, Data de Julgamento: 29/06/2021, 6º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/06/2021- grifei).

Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas - Preliminar de nulidade - Ilegalidade da prisão, efetuada por guardas civis - Réus em situação de flagrância, cuja prisão pode ser efetuada por qualquer pessoa - Artigo 301 do CPP - Preliminar rejeitada - Provas suficientes à condenação - Materialidade e autoria comprovadas - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Apreensão de

significativa quantidade de maconha em poder dos acusados - Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros - Penas-base fixadas em seus patamares mínimos - Circunstância atenuante da menoridade relativa reconhecida, mas sem reflexo nas penas - Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas - Redução que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida - Regime inicial fechado mantido - Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Rejeitada a preliminar, recursos de apelação desprovidos. Apelação da Justiça Pública - Associação para o tráfico de drogas - Fragilidade do conjunto probatório - Circunstâncias que parecem indicar mero concurso eventual de agentes e não associação de cunho permanente - Absolvição mantida - Colaboração com o tráfico de drogas na condição de informante - Hipótese de coautoria - Ré que decidiu atuar na venda de drogas em comparsaria com sua companheira, havendo a divisão de tarefas e de lucros entre ambas - Crime subsidiário aplicável somente à colaboração eventual e desvinculada do efetivo comércio de entorpecentes - Condenação pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 - Pena-base fixada em seu patamar mínimo - Circunstância atenuante da menoridade relativa reconhecida, mas sem reflexo na pena - Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas - Redução que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida - Regime inicial fechado - Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Recurso de apelação parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15029258520198260079 SP 1502925-85.2019.8.26.0079, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 25/06/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/06/2021)

II - Do mérito

No mérito, a ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitativa está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10.

2) Da autoria

A autoria criminoso ficou cabalmente demonstrada nos autos.

Na fase investigativa, o réu permaneceu em silêncio (fls. 05).

Em Juízo, o réu disse que não possuía a moto e não andou nela. Não tinha conhecimento da moto. É inocente. Estava cortando o cabelo, no cabeleireiro, viu os policiais e continuou no local. Os policiais ficaram passando na frente, até que pediram que todos saíssem do salão. Um policial falou que lembrava dele e que era irmão do Erick. Eles queriam saber da moto roubada e de seu irmão. Não sabia nada deles. O cabeleireiro disse que seria o próximo a cortar o cabelo, mas mesmo assim foi conduzido. A moto estava a 03 ou 04 casas. Quando chegou na Delegacia, explicou todo o ocorrido. Sua mãe também falou que não era ele. O Delegado os escutou, falou com os policiais e perguntou se o irmão iria assumir. Hoje, seu irmão foi homem e assumiu.

As alegações do réu, no entanto, foram afastadas pelo conjunto probatório juntado aos autos. Vejamos.

A vítima J.M.R. declarou que sua moto Twister foi furtada. Estava dentro do bar e, quando saiu, ela não estava mais estacionada. Fez boletim de ocorrência. Depois de algum tempo, a Polícia o avisou que a moto tinha sido localizada e que teria que ir à Delegacia. Chegando lá, a moto já tinha sido apreendida e estava no pátio, onde está até hoje. A moto era sua mesmo, mas o documento estava no nome de outra pessoa. A moto estava toda danificada e pintada de outra cor. Sua moto era amarela e, quando foi até a Delegacia, ela tinha sido pintada de vermelho. O GCM localizou a moto num bairro perto do Novo Horizonte. O delegado lhe disse que havia duas pessoas presas, mas não chegou a vê-las (fls. 99/101).

O guarda municipal Francisco Dernival Miranda Junior relatou que estavam em

patrulhamento, quando um senhor os solicitou e informou que dentro da comunidade Portelinha, havia um indivíduo Erick estaria dirigindo uma motocicleta vermelha causando perigo aos moradores. Solicitaram o apoio de uma equipe de motocicleta, porque a viatura de 04 rodas não consegue ingressar na comunidade. Fizeram a incursão a pé. Andaram um pouco e já visualizaram o réu pilotando a motocicleta vermelha e tentando fazê-la funcionar. Quando percebeu a presença dos guardas civis, ele largou a motocicleta e tentou fugir, mas foi abordado. Ele inicialmente disse de chamar Gabriel, no entanto, acabou reconhecendo o réu, porque já o tinha apreendido, quando adolescente, na posse de veículo subtraído. Quando percebeu que o tinha reconhecido, o réu já deu a qualificação correta. Pesquisaram a placa da motocicleta, constatando que era de um veículo Ford/Ka, de Belo Horizonte. Depois, pelo número do chassi, constataram que era uma motocicleta furtada, de cor amarela, embora ela aparentasse ser vermelha. Ela tinha sido pintada a mão. Na Delegacia, o réu disse que a motocicleta era de seu irmão Erick. Sobre os fatos, isso foi a única coisa que o réu mencionou. A pintura da moto era bem grotesca, nada profissional. A placa ostentada pela moto era visivelmente artesanal (fls. 99/101). No mesmo sentido, o também guarda municipal Felipe Vieira Alves respondeu que estavam em patrulhamento, quando um senhor solicitou a equipe e declinou que morava na comunidade Portelinha e que lá, um indivíduo de nome Erick estava numa motocicleta fazendo manobras perigosas e que a moto poderia ser produto de crime. Pediram apoio à uma equipe de motocicleta e fizeram a incursão na comunidade. Logo que ingressaram, encontraram o réu tentando fazer a motocicleta pegar. Assim que avistou os guardas, o réu deixou a moto e tentou fugir. Ele foi abordado e indicou nome falso, mas seu parceiro já o tinha apreendido quando adolescente e, por isso, o réu acabou indicando seu nome verdadeiro. Indagado sobre a moto, o réu anda falou. Pesquisaram o número do chassi e descobriram que se tratava de uma moto vermelha, produto de furto. A motocicleta estava vermelha, tinha sido pintada por spray. Na Delegacia, o réu falou que a moto era de seu irmão Erick. O réu não comentou o motivo pelo qual a moto estava em seu poder. Era nítido que a moto tinha sido pintada, era uma pintura bem grotesca. A moto tinha uma placa artesanal que, pesquisada, dava que era de um veículo Ford/Ka, de fora da cidade. Era visivelmente artesanal, aquela placa. Erick não foi ouvido, porque o réu não soube dizer qual era a residência correta dele. Logo que chegaram à Delegacia, sem a presença do Delegado, o réu disse que a moto era do irmão. Possivelmente não acompanhou a oitiva do réu, pelo Delegado, porque não é esse o procedimento padrão (fls. 99/101). Erick Adriano Tertuliano Augusto, irmão do réu, falou que a moto estava com ele. Seu irmão não tem nada a ver com o BO. A moto estava parada. Alguém soube que a moto era sua e contou aos policiais. Seu irmão foi detido, quando cortava o cabelo. Estava na casa do seu pai. Não viu o irmão sendo abordado, só viu o momento em que o irmão foi levado à Delegacia. Seu irmão não estava usando sua moto. Quem adquiriu a moto era ele. Quem dava volta e empinava a moto era ele e não o irmão. No mesmo dia, tinha andado com a moto, mas avistou a viatura e a deixou parada, indo para a casa do seu pai. Não sabe se foram os mesmos policiais que o viram que detiveram seu irmão.

No que se refere à receptação, está ela comprovada, porquanto a motocicleta tinha sido furtada anteriormente (boletim de ocorrência de fls. 63/64).

Resta saber se o réu estava ou não em posse da motocicleta.

Os guardas civis foram unânimes em afirmar que o réu estava sobre a motocicleta, quando ocorreu a abordagem. O irmão do réu alegou que a moto não estava com o réu, embora não tenha visto o momento da abordagem.

De fato, a denúncia era contra Erick, no entanto, foi com o réu que a moto foi visualizada.

Então, considerando que a única testemunha de defesa ouvida não presenciou a abordagem, é certo que a versão dos guardas civis deve prevalecer.

De mais a mais, importante mencionar que ainda que a moto estivesse com Erick, o fato é que foi com o réu que ela foi encontrada pelos guardas civis.

De outro lado, importante notar que o réu afirmou que estava cortando o cabelo, no entanto, o suposto cabeleireiro, que poderia ter sido arrolado como testemunha, não o foi.

A prova, portanto, confirma a denúncia, no sentido de que o réu estava em poder da motocicleta, ainda que a tenha recebido do irmão, apenas para dar algumas voltas. Nesses termos, necessário saber se o réu tinha conhecimento da origem ilícita do veículo.

O elemento subjetivo, porque interno, deve ser apreciado diante das circunstâncias objetivas e externas e conduzem à convicção de que o réu tinha conhecimento da origem espúria do bem.

Os policiais contaram que, inicialmente, receberam denúncia de que, na comunidade Portelinha, Erick estaria realizando manobras perigosas com uma motocicleta vermelha que, possivelmente, tratava-se de produto de crime anterior. Dirigiram-se até a comunidade, onde visualizaram o réu na posse da moto vermelha, tentando acionar o motor dela. Ao avistar o policiamento, o réu abandonou a motocicleta e tentou se evadir. Essa conduta já demonstra que tinha conhecimento da ilicitude do veículo que pilotava.

A motocicleta ostentava uma placa artesanal RFF-9030, que pertencia a um veículo Ford/Ka de Belo Horizonte, e estava pintada, visivelmente de forma rudimentar, com spray, de vermelho, ou seja, a sua real situação estava sendo escondida. E essas situações eram visíveis a olho nu, sem necessidade de qualquer especial habilidade. De mais a mais, o réu tinha convívio com o irmão e, por isso, saberia da sua situação financeira a autorizar ou não a aquisição de motocicleta lícita.

Assim, ainda que a motocicleta estivesse na posse inicial do irmão do réu, no momento em que fez dela uso, o réu tinha conhecimento de que ela tinha origem ilícita e, portanto, praticou o delito.

Com efeito, todos esses elementos indicam que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

Diz a jurisprudência:

Apelação criminal. Receptação dolosa e condução de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade dos crimes bem comprovadas. Negativa do réu refutada pelas demais provas. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores. Circunstâncias que revelaram, à exaustão, que o réu detinha ciência da origem viciada do automóvel, sem desprezar que se omitiu na produção de qualquer prova em favor de sua inocência. Crime de trânsito também evidenciado. Condenação mantida. Penas dosadas sem excesso. Recurso não provido, com anotação. (TJSP; Apelação Criminal 0001735-50.2016.8.26.0635; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020).

RECEPTAÇÃO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE DOLO - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - DOLO EVIDENCIADO - PENA E REGIME ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0011016-68.2018.8.26.0050; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020).

Receptação - Recebimento de veículo sabidamente produto de ilícito comprovada - Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos - Condenação mantida - Privilégio descabido - Pena e regime fixados com correção - Restrição da pena substitutiva à prestação de serviços à comunidade - Inteligência do § 2º do artigo 44 do Código Penal - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0002785-42.2017.8.26.0291; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaboticabal - Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020).

Caracterizado está, pois, o dolo do agente, sendo incabível a desclassificação para a receptação culposa.

De outro lado, verifica-se que o réu foi abordado na posse do bem e, portanto, cabia a ele o dever de comprovar a posse lícita da motocicleta. Nesse sentido:

Apelação. Receptação. Art. 180, caput, do CP. Sentença absolutória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Recurso do Ministério Público. Autoria que se comprova por meio da posse de celular objeto de roubo precedente, cabendo ao possuidor demonstrar a licitude de sua posse, ônus do qual o apelado não se desincumbiu. Condenação pela receptação, impondo-se a pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como o pagamento de 10 dias-multa, fixado seu valor unitário no piso legal. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0037404-08.2018.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPÇÃO (Artigo 180, "caput", do Código Penal). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE QUE EMERGEM CRISTALINAS DOS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO COMPROVADO. Pena-base fixada no mínimo legal e manutenção do regime inicial semiaberto - Recorrente reincidente. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0043328-97.2018.8.26.0050; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal